

1511642-22.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511642-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511642-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2130820/2022 - 33º Distrito Policial - Pirituba, B06901-1/2022 - 33º Distrito Policial - Pirituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DYOGO DA SILVA MACHADO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 785/22

VISTOS.

DYOGO DA SILVA MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 13 de maio de 2022, por volta das 08:20 horas, na Rua César Augusto Costalonga Varejão, altura do n.º 180, Jardim Santa Lucrécia, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, trazia consigo 99 porções contendo 12,2 gramas de "crack", 46 porções contendo 35,5 gramas de "maconha", 1 envelope contendo 0,1 grama de 25BNBOH e 59 porções contendo 21,8 gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida à fl. 82.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 106.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/28, dando conta das 59 porções de cocaína; das 46 porções de maconha, das 99 porções de crack, 01 (um) envelope contendo 0,1 grama de 25BNBOH além da quantia de R\$ 119,00, localizados e apreendidos em poder do réu e do seu comparsa.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 91/93, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahydrocannabinol, cocaína e 25b-nboh (2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenil)etil]amino)metil)fenol).

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos da douta Defensoria Pública não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia o réu declarou que é usuário de maconha. Estava lá para comprar droga. O Traficante, chamado Gabriel, que correu, me pediu ajuda para contar a droga que estava com ele e eu ajudei. Quando os guardas chegaram eu estava contando a droga com o traficante. Já tinha ajudado ele antes, fls. 11.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu alterou sua versão dizendo que eu fui no local para comprar maconha. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Depois Gabriel chegou, e foi no mato buscar as drogas. Ele falou vem aqui, e depois largou a sacola no chão e correu. Não conhecia os policiais. Tenho 19 anos de idade e nunca fui processado antes.

Enquanto a confissão extrajudicial do réu veio de encontro com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, suas negativas judiciais restaram isoladas e em absoluto não convenceram.

O réu não apresentou, em Juízo, qualquer versão plausível para sua prisão. Limitou-se a dizer o que todos dizem quando são surpreendidos em poder de grande quantidade de drogas ou seja, que estava no local apenas para comprar drogas porque é usuário, quando o verdadeiro traficante fugiu e acabou sendo preso injustamente.

Ocorre porém que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, prender o réu e deixar o verdadeiro traficante fugir, acusa-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes e dinheiro, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais.

Mesmo porque, não se pode crer que o réu estivesse com tamanha quantidade e variedade de drogas em seu poder, não fosse para o exercício da traficância. Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o

crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita do réu, sua abordagem a grande quantidade e variedade de drogas encontradas, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que os guardas civis metropolitanas responsáveis pela prisão do réu, Júlio Cesar Moreira da Silva e Renato Gomes Maciel, ouvidos em Juízo, relataram de forma firme, segura, e em uma só voz que estávamos em patrulhamento pelo local dos fatos, quando vimos os dois indivíduos agachados mexendo em umas sacolas no chão. Aos nos aproximarmos, eles largaram as sacolas e tentaram fugir. Apenas o réu foi detido. Na sacola dele havia crack e 119 reais, e na outra sacola estava o restante das drogas. O réu disse que era apenas usuário. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente.

Os guardas civis narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, o momento em que avistaram o réu e mais um indivíduo atrás de um veículo mexendo em umas das sacolas no chão; a abordagem, suas tentativas de fuga, o momento em que o outro indivíduo dispensou uma sacola também com drogas, o encontro das drogas e dinheiro dentro da sacola em que o réu mexia, até final detenção e prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade e variedade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia.

E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de condicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de condicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

O fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários.

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é menor de 21 anos de idade, primário, e não ostenta antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena base já fixada no mínimo legal não pode ser mais reduzida pela menoridade relativa, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de crack, reduzo a pena base em 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar DYOGO DA SILVA MACHADO, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo e compareceu em todos os atos para os quais foi chamado, sendo que fazê-lo retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade

em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA